

Preface

© 版权所有，不可随意转载

本次整理综合毛玲玲和马寅翔两位老师的期末重点强调内容，并结合两位老师日常上课笔记而得。

重要交集部分（必考）会用该颜色标出。考试考法会用该颜色标出。综合各老师理论与分析方式写的案例分析会用该颜色标出。批注解释会用该颜色标出。

华政法律学院 24010102016

第一章 刑法概述

1. 刑法：规定**犯罪**、**刑事责任**与**刑罚**的法律规范的总和

2. 刑法的渊源：【必考】

(1) 刑法典 exl：包括79和97那的两部《中华人民共和国刑法》

(2) 单行刑法：（国家以决定、规定、补充规定、条例等名称颁布的，）规定某一类犯罪及刑事责任或者刑法的某一事项的法律

exl：目前唯一单行刑法1998年《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》（mll）

(3) 附属刑法：非刑事法律中的罪行规范——附属刑法规范中均没有规定具体的构成要件与法定刑，适用时回到刑法具体规定

★ 刑法修正案不是刑法的渊源「作为刑法典的一部分，不可成为独立刑法渊源」

3. 刑法的形式上分类

(1) 广义刑法：一切有关犯罪、刑事责任和刑罚法律规范的总和。包括刑法典、单行刑法和附属刑法。

(2) 狭义刑法：仅指刑法典

4. 刑法的其他各种分类

刑法是固有法（对标继受法）、刑事法、实体法（对标程序法）、强行法（对标任意法、司法法（对标行政法）

5. 刑法的任务：惩罚犯罪+保护人民、社会、国家

6. 1979年刑法特点：

(1) 反革命罪与其他严重刑事犯罪是打击锋芒

(2) 带有强烈的计划体制痕迹

(3) 刑罚方式较为轻缓

(4) 罪状设置宜粗不宜细（口袋罪：投机倒把罪、流氓罪、玩忽职守罪）

(5) 允许采用类推

7. 但书★【必考】

▲ T13：情节显著轻微危害性不大的，不认为是犯罪——完全不是犯罪

▲ T37：犯罪情节轻微，不需要判处刑罚的，可以免于刑事处罚——（1）构成犯罪但是不加以处罚，有犯罪记录（2）结合《刑事诉讼法》第177条，有认罪认罚、自首、被害人原谅等情节，检察机关可以作出“酌定不起诉”的结果，无犯罪记录

▲ 《刑事诉讼法》第177条第2款：酌定不起诉

8. 刑法的解释【必考】

(1) 解释效力角度

① 有权解释：立法解释、司法解释

② 学理解释

(2) 解释方法角度

① 文理解释

② 论理解释：「“下列属于论理解释的是…”」

【扩张解释】将刑法作大于其字面含义范围的解释“审判的时候怀孕的妇女”——执行前怀孕的妇女；淫书淫画—淫秽录像、影片、电视片、幻灯片等

【限制解释】将刑法作小于其字面含义范围的解释“情节恶劣、后果严重的，应该依照xxx的规定从重处罚”

【当然解释】该事项当然包含在该规范适用范围之内的解释

★ 刑法存在兜底条款

第二章 刑法的基本原则

1. 罪刑法定原则 ★★★★★ 【必考】

(1) 概念：法律明文规定为犯罪行为的，依照法律定罪处罚；法律没有明文规定为犯罪行为的，不得定罪处罚。

(2) 罪刑法定原则的具体要求/派生原则

① 排斥习惯法（习惯法：人们的交往习惯；我国认可：国家制定和颁布的法律）

② 排斥绝对不定期刑（相对不定期刑：给出一个大概的范围，符合罪责刑相适应原则；绝对定期刑：符合立法精神，如航空器罪）

③ 禁止有罪类推（类推解释）（比赋类似的事例进行解释）

④ 禁止重法溯及过往

a. 按照有利于被告人原则存在“从旧兼从轻”的例外

b. （已判决）对已判决的案件不可更改，不适用“从旧兼从轻”

c. （重判）【必考】事实认定与法律适用有区别——可以提出法律监督程序中的再审，但是再审中不适用“从旧兼从轻”

「将上述要求/原则（习惯法等）替换成具体表述出选择」

2. 平等适用原则、罪责刑相适应原则

「“刑法中xx条文因为yy违反了平等适用原则、罪责刑相适应原则”——错，只要刑法有这个规定就没有违反平等适用/罪责刑相适应原则」

第三章 刑法的效力范围

一、刑法的空间效力

1. 刑法的空间效力各原则解释 (背) 【必考之一】

➤ 第六条【属地原则】凡在中华人民共和国领域内犯罪的，除法律有特别规定的以外，都适用本法。

凡在中华人民共和国船舶或者航空器内犯罪的，也适用本法。

犯罪的行为或者结果有一项发生在中华人民共和国领域内的，就认为是在中华人民共和国领域内犯罪。

➤ 第七条【属人原则】中华人民共和国公民在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的，适用本法，但是按本法规定的最高刑为三年以下有期徒刑的，可以不予追究。中华人民共和国国家工作人员和军人在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的，适用本法。

➤ 第八条【保护原则】外国人在中华人民共和国领域外对中华人民共和国国家或者公民犯罪，而按本法规定的最低刑为三年以上有期徒刑的，可以适用本法，但是按照犯罪地的法律不受处罚的除外。

➤ 第九条【普遍原则】对于中华人民共和国缔结或者参加的国际条约所规定的罪行，中华人民共和国在所承担条约义务的范围内行使刑事管辖权的，适用本法。

➤ 第十条 凡在中华人民共和国领域外犯罪，依照本法应当负刑事责任的，虽然经过外国审判，仍然可以依照本法追究，但是在外国已经受过刑罚处罚的，可以免除或者减轻处罚。

2. 使用原则顺序：属地→属人→保护→普遍

- 国内犯，一律适用属地管辖（属地优先）
- 国外犯，再考虑其他三种管辖

3. 属地原则 【必考】

(1) 犯罪行为或结果有一个发生在我国内部就可以属地（包括共同犯罪的预备行为）（犯罪完成之后的转移赃物、消灭罪证等行为不能视为行为地或者结果地）

(2) 中华人民共和国领土包括船舶、航空器（不包括国际列车）、外国驻中国大使馆

(3) 【例外】“（第六条）法律有特别规定的”

- ① 享有外交特权和豁免权的外国人的刑事责任，通过外交途径解决
- ② 民族自治地方获批准实行的变通或补充性规定
- ③ 刑法实施后国家立法机关制定的特别刑法的规定
- ④ 港澳地区基本法的例外规定

4. 普遍原则

第九条【普遍原则】对于中华人民共和国缔结或者参加的国际条约所规定的罪行，中华人民共和国在所承担条约义务的范围内行使刑事管辖权的，适用本法。

(1) 普遍原则的法律基础并非本国刑法，而是国际公约和条约，对象仅限于国际犯罪，如**海盗、劫持航空器罪**、违反人道主义犯罪、恐怖主义犯罪（如暗杀政治家）、战争罪行（如发动侵略战争）、灭绝种族罪、**毒品犯罪**等罪行

(2) 宣判国际罪行的法律依据是我国刑法规定

二、刑法的时间效力——溯及力

1. 刑法溯及力解释——“从旧兼从轻”意思【论述】

第十二条 中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律；如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。

本法施行以前，依照当时的法律已经作出的生效判决，继续有效。

2. “从轻”的比较标准是**法定刑**，不是实际宣告刑

3. 从旧兼从轻注意

a. 按照有利于被告人原则存在“从旧兼从轻”的例外

b. （已判决）对已判决的案件不可更改，不适用“从旧兼从轻”

c. （重判）【必考】事实认定与法律适用有区别——可以提出法律监督程序中

第四章 犯罪概述

1. 犯罪概念

刑事违法性（形式概念）+ 严重社会危害性（实质概念 本质）+ 刑罚当罚性（派生）

2. 犯罪的理论分类（mlt：具体了解书上例子）

（1）自然犯 vs 法定犯罪

① 自然犯（刑事犯）：违反公共善良风俗和人类社会伦理的犯罪，其行为本身就自然蕴含着犯罪性，人们根据一般的伦理观念即可对其作出有罪评价。（传统型犯罪）

故意杀人、抢劫、强奸、放火、爆炸、盗窃

② 法定犯（行政犯）：对于行为的犯罪性质，不能通过社会伦理直接进行判断，而是要根据刑罚法规的规定才能确定的犯罪。违反行政法规中的禁止性规范，并由行政法规中的刑事法则（附属刑法的一种）所规定的犯罪。（特点在于都以**违反一定的经济、行政法规为前提**，它们原来都没有被认为是犯罪，由于社会情况的变化，在一些经济、行政法规中首先作为被禁止的行为或作为犯罪加以规定，随后在刑法修订时被加以吸收从而在刑法典中被正式确立为犯罪。）

（2）身份犯 vs 非身份犯

① 身份犯

～典型的身份犯/纯正的身份犯：以国家工作人员、公司企业工作人员、司法工作人员等一定的身份作为构成犯罪的主体条件的犯罪。贪污罪、受贿罪、玩忽职守罪、滥用职权罪等

～不典型的身份犯：指主体是否具备某种身份会影响量刑处罚轻重的犯罪。诬告陷害罪（国家机关工作人员犯本罪的要比一般主体接受更重的刑罚处罚）

② 非身份犯：刑法对犯罪主体条件未作特别限定，仅以一般人作为犯罪主体条件的犯罪。故意杀人罪、故意伤害罪、聚众斗殴罪、盗窃罪、诈骗罪、抢劫罪

(3) 行为犯 vs 结果犯 ★ 补充-作用：区分犯罪是否既遂

① 行为犯：以侵害行为的实施为构成要件的犯罪，或者是以侵害行为实施完毕而成立犯罪既遂状态的犯罪。（只实施特定的举动，犯罪就已经既遂）

前者如强奸罪、煽动分裂国家罪、煽动颠覆国家政权罪等；后者如诬告陷害罪、伪证罪、偷越国(边)境罪等；聚众淫乱罪（典）★【结合案例情景考察】

② 结果犯：以侵害行为产生相应的法定结果为构成要件的犯罪，或者是指以侵害结果的出现而成立犯罪既遂状态的犯罪。（必须产生特定的法定结果）

前者如玩忽职守罪、交通肇事罪、过失致人死亡罪等所有的过失犯罪；后者如故意杀人罪、盗窃罪、贪污罪、敲诈勒索罪等。故意杀人罪（典）★【结合案例情景考察】

(4) 实害犯 vs 危险犯 ★ 补充-作用：区分犯罪是否成立

① 实害犯：以出现法定的危害结果为构成要件的犯罪。（需要造成实际的危害结果）

过失损坏交通工具罪等★【结合案例情景考察】

② 危险犯：指以实施危害行为并出现某种法定危险状态为构成要件的犯罪。（推定这种举动具有严重的危险性，提前打击犯罪需要，不需要造成实际的危害结果）

破坏交通工具罪（具体危险犯），非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支 & 弹药、爆炸物罪，非法制造、买卖、运输、存储危险物质罪（抽象危险犯）★【结合案例情景考察】

3. 犯罪在立法上的分类 (ml: 具体了解书上例子)

(1) 亲告罪 vs 非亲告罪

① 亲告罪：告诉才处理的犯罪，它们不属于公诉案件，必须由被害人或其近亲属自己到人民法院提起诉讼时，法院才予以受理。（行为人和被害人之间有特定关系，尤其亲友关系，采取“不告不理”）

「★侮辱、诽谤、暴力干涉婚姻自由、虐待（后果较为严重时成为为公诉案件）、侵占（、亲友盗窃罪：特定亲友之间取得谅解的不认为是犯罪）」

② 非亲告罪：除亲告罪以外的其他犯罪，都是非亲告罪，需要由公安机关、检察机关立案侦查，并由检察机关代表国家提起公诉。

(2) 自然人犯罪 vs 单位犯罪

★注意：处罚特定单位的举动会在刑法分则中具体规定，没有规定的只能由自然人构成

第五章 犯罪构成

1. 【案例（见后）】

2. 犯罪构成的类型（mll要求结合myx日常笔记）

（1）基本的犯罪构成 vs 修正的犯罪构成

- ① 基本的犯罪构成：假定一个刑法分则规定的罪名是既遂的完满状态——一个人犯一个罪的既遂
 - ② 修正的犯罪构成：上述各个要素全部作修正（修正的构成要件要素）：
 - （1）一个人→两个及以上的人——共同犯罪 对犯罪主体的修正
 - （2）一个罪→多个罪——对罪数的修正
 - （3）既遂→未遂——对于结果的修正
- （2）简单的犯罪构成 vs 复杂的犯罪构成

第六章 犯罪客体要件

1. 犯罪客体概念的学说与理论变化（了解）

- （1）刑事古典学派：犯罪客体只是那些规定抑制实行某种行为(禁止)或者规定实行一定行为(命令)的法律规范——犯罪仅仅是违反法律规范的行为。
- （2）德国刑法学家李斯特为代表的刑事社会学派：犯罪客体是某种法益，即由法律所保护的生活利益，从而认为刑法无所谓“阶级性”可言，它将对社会中各个人的生存条件及每一个社会成员的利益均予以必要的保障。
- （3）一些大陆法系刑法学者还提出了犯罪客体就是犯罪对象的主张：犯罪对象有被害法益和被害人，被害法益是财产、物品等,这些都是犯罪客体。
- （4）我国刑法学理论以马克思主义为指导：指我国刑法所保护的，为犯罪行为所侵犯的社会关系。

第七章 犯罪客观要件

1. 危害行为的概念：指在人的意志支配下实施的危害社会的身体动静

特征：举止性（作为不作为）+自愿性+有害性+刑事违法性

2. 教材上不属于危害行为的行为：【必考】

不表现人的意识和意志的行为（P100）：

- ① 人在睡梦中或者无意识状态（如精神错乱）下的行为/无责任能力人实施的行为
- ② 在不可抗力作用下的行为

发生洪水桥梁被冲垮使得医务人员不能及时赶到现场

- ③ 人在身体受强制情况下的行为
- ④ 反射性动作

【特殊·必考】醉酒

《刑法》第18条第4款 醉酒的人犯罪，应当负刑事责任。

- ① 病理性醉酒：少量饮酒即可引起的严重精神障碍——不具备刑事责任能力
- ② 生理性醉酒：单纯性醉酒，即饮酒过量导致的精神过度兴奋甚至神智不清的情况——应当负刑事责任

【特殊·myx】毒驾（比照醉驾）不纳入刑法的原因

毒驾的危险性虽然高，但相较于酒驾、醉驾等已有明确法律规定的危险驾驶行为，其在实践中的普遍性和危害性可能还未达到需要单独入刑的程度。此外，毒驾的认定也存在一定的技术难度，如毒品种类繁多，不同毒品对人体的影响也各不相同，这给毒驾的认定带来了一定的复杂性。

★★★不作为★★★：

3. 不作为犯罪概念（背）

指行为人负有实施某种行为的特定法律义务，能够履行而不履行的危害行为，即“**应为而不为**”。

从表现形式看，不作为是消极的活动或身体的静止；从违反法律规范的性质看，不作为是违反**命令性规范**的行为。

4. 不作为犯罪的成立条件（背-分析用）

- (1) 前提条件：行为人负有实施某种行为的特定法律义务

★注意：是法律性质义务而非道义上的义务；是实施积极行为的义务而非不实施一定积极行为的消极义务。

- (2) 重要条件：行为人有能力履行特定义务
- (3) 关键条件：行为人没有履行该特定义务

【总结】“**有义务、能履行、未履行、有结果**”

5. 纯正不作为犯罪名（了解-mll）

- (1) 丢失枪支不报罪（129）
- (2) 不报安全事故罪（139条第1款）
- (3) 遗弃罪（261）
- (4) 拒不支付劳动报酬罪（276第1款）
- (5) 拒绝提供间谍犯罪、恐怖主义犯罪、极端主义犯罪证据罪（311）
- (6) 拒不执行判决、裁定罪（313）
- (7) 不解救被拐卖、绑架妇女、儿童罪（416条第1款）

6. 不纯正不作为犯义务来源【必考】（“实质义务来源”为myx笔记，可用于分析案例）

（1）形式义务来源

① 法律上明文规定的义务

必须是**刑法**上加以确认的义务（不可以只是前置部门法规而刑法未确认）

② 职务、业务上要求履行的义务

必须注意次义务所针对的对象和时限

警察具有阻止犯罪的义务，不分上班下班；医生确并不要求这么高的救助义务（医生的救助需要一定的医疗资源）；教师也只需要完成学校规章制度的义务，后续是责任心有无的问题不是义务问题（如邮件24小时待命）

③ 行为人实施的法律行为而引起的义务【必考】【案例（大概率）】

（教材一般通说）

根据约定暂时抚养他人婴儿的人对该婴儿有抚养义务；将弃婴抱回家中的人对该婴儿负有抚养义务。

（myx笔记分析）

主要是**合同行为**和**承诺（自愿）行为**引起的义务

【衍生】承诺（自愿）行为一旦开始可以反悔吗？（“好人一定要做到底吗”）

看是否创设/提高/实现法所不允许的危险

再看有没有新的义务（其他行为的选择空间）

（二者结合分析）

将弃婴抱回家中的人，后再次遗弃回原处使得小女孩冻死，属于不作为犯罪吗？——【分析】构成不作为犯罪。（概念解释）不作为指行为人负有实施某种行为的特定法律义务，能够履行而不履行的危害行为，即“应为而不为”。（案例融入）此处该人先前将弃婴抱回家的行为产生了抚养义务，然而此人后续反悔时，本可以将小女孩送至当地民政部门等履行自己的义务，但是却将其放回原处，为该主体创设了法所不允许的危险，产生了危害结果。

④ 由先行行为产生的义务

（myx笔记，无需掌握）

A. 合法的先行行为一般不引起救助义务，主要看合法行为有没有创设法所不允许的危险

B. 犯罪行为会不会引起作为义务？

a. 看是否故意 b. （过失）主要看行为当时有没有救助可能性

（教材通说，需掌握）

一般认为先行行为不包括犯罪行为

★★★因果关系★★★：

7. 因果关系条件说

行为与结果之间存在“没有前者就没有后者”的条件关系时，前者就是后者的原因。

8. 相当因果关系说

根据一般人的社会经验，在通常情况下，某种行为产生某种结果被认为是相当场合，就认定该行为和结果有因果关系。

→折中说：

主张以一般人能认识到的以及行为人特别认识到的事实为基础进行判断

行为时一般人能知道乙是血友病患者或者甲特别清楚的知道乙是血友病患者

9. 因果关系判断方法★（综合教材，myx笔记 plus通用版）【案例】

STEP 1：判断是一个行为还是两个行为——一个行为不存在因果关系判断，只需要事实上判断结果如何产生了（一因一果）

（涉及多因一果：先筛原因）

STEP 2：（行为判断）行为人的行为有没有制造刑法所不允许的危险「标准：行为在具体案件中有没有制造具体的人所承受不住的危险（另：注意义务判断也按照具体的人的标准）」

STEP 3：（行为能否覆盖结果）看行为和结果是否具有强关联性，即只要行为就一定结果，以此判断结果能否被行为覆盖

【简化】判断是否存在客观注意义务

客观注意义务判断：折中说 【例外】特殊体质「公平分配原理」

（若还是多因：再看顺序）

STEP 4（顺序先后）：因果关系中断说——看介入因素是替代（异常）/重叠/择一

10. ★注意：主观狭义因果关系错误不妨碍结果的归属【必考】

第八章 犯罪主体要件

1. 刑法上对于犯罪主体的认定

指实行危害社会的行为，依法应当负刑事责任的自然人和单位。

2. 自然人刑事责任年龄划分（717）

（1）12周岁以下：完全无刑事责任能力

（2）12-14周岁：犯故意杀人、故意伤害罪，致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾，情节恶劣，经最高人民检察院核准追诉的，应当负刑事责任

（T17K3）

（3）14-16周岁：犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任（T17K2）

（4）16周岁以上：完全刑事责任能力

★注意：八大罪规定的是罪行，不是罪名；K2不包括绑架；和毒品有关的一定是贩卖【必考】

3. 未成年人犯罪的特殊处罚原则 (ml)

- (1) 从宽处理：(T7K4) 不满18周岁的人犯罪，应当从轻或减轻处罚
- (2) 不适用死刑：(T49K1) 犯罪的时候不满18周岁的人，不适用死刑
- (3) 不适用累犯：(T65K1) 犯罪的时候不满18周岁的人，不适用累犯
- (4) 应当适用缓刑：(T72K1) 审判时不满18周岁，符合条件的，应当适用缓刑
- (5) 免除前科报告义务：(T100K2) 犯罪的时候不满18周岁被判处5年以下有期徒刑的

4. 老年人犯罪的特殊处罚原则 【必考】

- (1) 从宽处罚：(T17Z1) 已满75周岁的人故意犯罪的，可以从轻或者减轻处罚；过失犯罪的，应当从轻或者减轻处罚。
- (2) 慎用死刑：(T49K2) 审判的时候已满75周岁的人，不适用死刑，但以特别残忍手段致人死亡的除外
- (3) 适用缓刑：(T72K1) 审判时已满75周岁，符合条件的，应当适用缓刑。

5. 【对比】未成年人和老年人特殊处罚原则 【必考】

- (1) 未成年人为“犯罪时”，老年人为“审判时”——均体现了“更有利于被告人”原则
- (2) 老年人的从宽处理区分故意和过失：故意为“可以”，过失为“应当”；未成年人不区分故意和过失，一律“应当”
- (3) 未成年人一律不适用死刑；老年人原则上不适用，但以特别残忍手段致人死亡的除外
- (4) 未成年人原则中还有“不适用累犯”以及“免除前科报告义务”

6. 【特殊·必考】醉酒

《刑法》第18条第4款 醉酒的人犯罪，应当负刑事责任。

- ① 病理性醉酒：少量饮酒即可引起的严重精神障碍——不具备刑事责任能力
- ② 生理性醉酒：单纯性醉酒，即饮酒过量导致的精神过度兴奋甚至神智不清的情况——应当负刑事责任

【特殊·myx】毒驾（比照醉驾）不纳入刑法的原因

毒驾的危险性虽然高，但相较于酒驾、醉驾等已有明确法律规定的危险驾驶行为，其在实践中的普遍性和危害性可能还未达到需要单独入刑的程度。此外，毒驾的认定也存在一定的技术难度，如毒品种类繁多，不同毒品对人体的影响也各不相同，这给毒驾的认定带来了一定的复杂性。

7. 生理功能状况

《刑法》第19条 又聋又哑的人或者盲人犯罪，可以从轻、减轻或者免除处罚。

- (1) 即聋又哑
- (2) 盲人：双目失明
- (3) 处罚原则为“可以”而不是“应当”

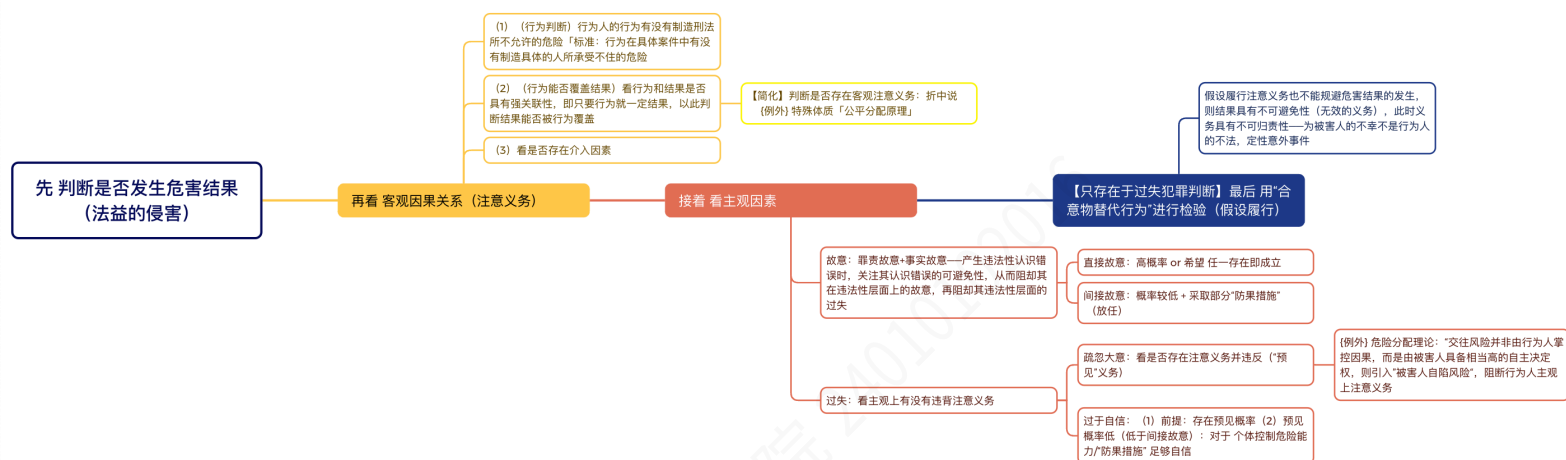
第九章 犯罪主观要件

1. 概念类 (背背背)

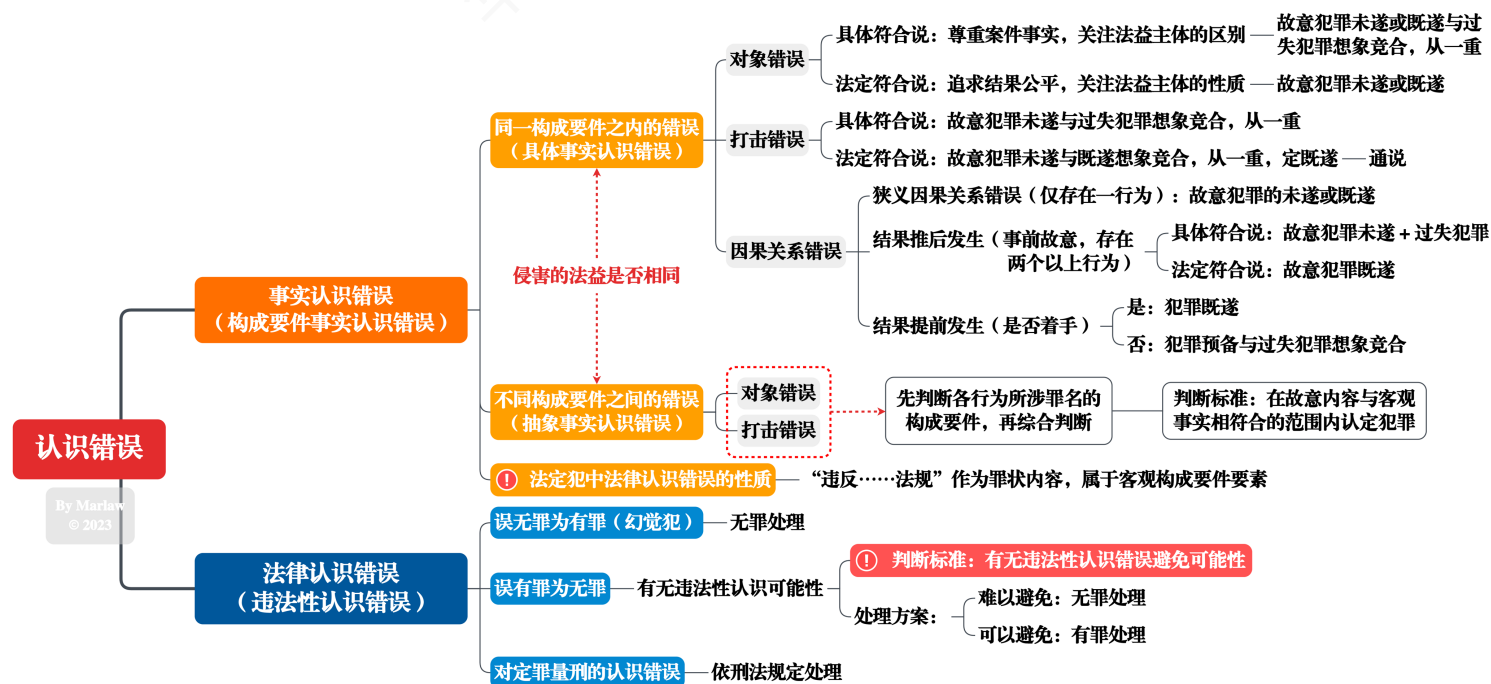
(1) 犯罪故意：指行为人明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望或者放任这种结果发生的一种主观心理态度。

(2) 犯罪过失：指行为人应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果，因为疏忽大意而没有预见，或者已经预见而轻信能够避免，以致发生这种结果的心理态度。

2. 案例分析总流程梳理 【案例分析必备★★★★】 (采用三阶层)



3. 认识错误 【案例分析必备★★★★】



「详细」判断事实认识错误

STEP 1: 具有事实上的危害结果（有法益的侵害）

【区别】（a）对象不能犯（不可处罚——无法益）误把稻草人当人

（b）手段不能犯（需要处罚——存在法益=狭义犯罪未遂）误把白糖当砒霜

糖当砒霜

（1）对象认识错误的法定符合说「机理：注重法益主体的平等」

对象错误

具体符合说：尊重案件事实，关注法益主体的区别——故意犯罪未遂或既遂与过失犯罪想象竞合，从一重

法定符合说：追求结果公平，关注法益主体的性质——故意犯罪未遂或既遂

（2）打击错误的法定符合说

打击错误

具体符合说：故意犯罪未遂与过失犯罪想象竞合，从一重

法定符合说：故意犯罪未遂与既遂想象竞合，从一重，定既遂——通说

（手段上存在瑕疵）想打的人未遂 & 不想打的人既遂 == 一个行为多个法益——想象竞合犯，从一重罪

（3）【补充】既有对象错误又有打击错误：分别分析，然后整体上再对对象错误与打击错误的结果想象竞合

（4）狭义因果关系错误：只有一个行为，行为和结果的发生之间存在一定背离（自己对于因果流程的设想和实际产生偏差）

【标准】看结果的风险是否能被行为覆盖——不影响定性 or 意外事件

（5）结果推后发生：两个行为，事先故意但误以为结果已经实现

【法定】将两个行为做一体化判断，故意犯罪既遂

（6）结果提前发生：没想到结果已经提前发生

结果提前发生（是否着手）

是：犯罪既遂

否：犯罪预备与过失犯罪想象竞合

【法定】判断是否着手（标准：中间行为说）

判断是否着手

是（看客观行为上能不能直接引发结果的发生，已经可以建立因果关系）

犯罪既遂

不是（则属于预备）

再看存不存在注意义务（确认是否存在“过失”的因素）

存在

犯罪预备与过失犯罪想象竞合

不存在

犯罪预备

（7）不同构成要件之间的事实要件错误

【方法】三步走：

① 行为人主观上意图实施这个行为能不能成立（这里是分析时“先客观再主观的例外”）

② 客观上触犯的罪名能不能成立（导致过失的原因：比如盗窃罪、猥亵强奸等无法成立过失；注意义务较低）

③ 综合判断要不要从轻或者免除处罚

第十章 违法阻却事由

★★★正当防卫★★★：【A卷·选择、论述、案例均有】

1. 正当防卫的概念（《刑法》第20条）（全背）【必考】

《刑法》第20条[一般正当防卫]为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他利益免受正在进行的不法侵害，而采取的制止不法侵害的行为，对不法侵害人造成损害的，属于正当防卫，不负刑事责任。

[防卫过当]正当防卫明显超过必要限度造成重大损害的，应当负刑事责任，但是应当减轻或者免除处罚。

[特殊正当防卫]对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪，采取防卫行为，造成不法侵害人伤亡的，不属于防卫过当，不负刑事责任。

2. 正当防卫构成要件以及判定【必考】

（1）防卫意图：为了保障合法的权益

★ 防卫意图不要求防卫认识的不法侵害和客观真实不法侵害对等，比如：为保护非法利益而实施的防卫也属于正当防卫

【注意】以下情景中防卫意图的判定：【必考】

① 防卫挑拨：故意用一些言语、举止刺激对方攻击

【判定】举动在交往中有没有制造出“交往危险”

【法定】不具有防卫意图，不存在正当防卫

② 互殴

【法定】不具有防卫意图，不存在正当防卫

【例外】以下虽有“互殴”情形，但成立正当防卫（myx笔记）

a. 互殴结束一方穷追不舍✓

b. 一方暴力侵害程度超出另一方预知✓

③ 偶然防卫：行为人基于犯罪意图实施的，却在结果上保护法益的举动（客观上存在不法侵害，但是行为人没有意识到不法侵害存在）

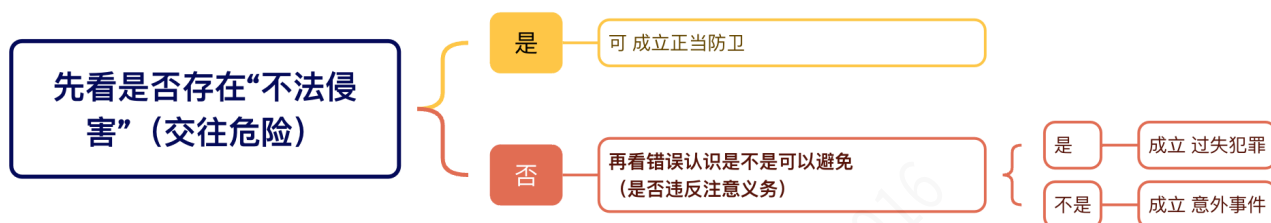
【法定】不具有防卫意图，不存在正当防卫

(2) 防卫起因：实行正当防卫须以不法侵害客观存在为前提【必考“不法侵害”判定】

I. 不法侵害程度：不一定达到犯罪的程度，轻微的违法即可「民法也存在正当防卫」

II. 不法侵害【判定】：即存在“**交往危险**”。“危险”的判断是按照社会交往经验判定的，不是第三方时候断定的。「标准：原则按照一般人“就高不就低”（对危险耐受低：若因特殊体质则按行为人标准；若为先前不法行为则按一般人标准考虑行为人过错进而成立过失）」

III. 假想防卫：不法侵害客观不存在，在错误认识之下实施的防卫行为【判定流程】



(3) 防卫对象：必须针对不法侵害人本人进行

(4) 防卫时间：不法侵害必须正在进行

I. 不法侵害“已开始”：先于“着手”，一旦意识到现时“交往危险”即可「机理：刑法上允许防卫人“先下手为强”」

II. 不法侵害“未结束”——防卫不适时：事先防卫、事后防卫

【判定】一旦处于“可能造成侵害”的风险中，就属于防卫时间

(5) 防卫限度：不能明显超过必要限度且对不法侵害人造成重大损害【必考】

【判定】看防卫危险行为和不法侵害危险行为是不是大致相当（大致相当：出于保护，防卫者可以部分提高防卫等级）+防卫行为结果是不是明显超出——兼备才成立防卫过当，否则都是正当防卫

3. 特殊防卫【必考】

《刑法》第20条第3款 对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪，采取防卫行为，造成不法侵害人伤亡的，不属于防卫过当，不负刑事责任。

1. 仅限“暴力犯罪”

2. “杀人”仅限故意杀人，对于转化型杀人、抢劫，关键看是否严重危及人身安全以及能否通过防卫阻止结果发生【考察防卫意图】（防卫的目的在于保护合法权益——如果没有合法权益来保护，就根本不成立正当防卫）
人已经中毒再打人一棒子纯属没有必要

3. “行凶”：关键看是否严重危及人身安全【必考】【论述】

(1) 不法侵害人已经使用了致命性武器，已经给他的人身安全造成重大威胁

(2) 没有使用致命性武器：根据当时举动也可以判定严重危及人身安全

4. 只有杀人、抢劫、强奸、绑架等行为**严重危及人身安全时才能适用**本款规定——指**罪行**而不是罪名 **使用暴力手段**
5. “**其他**”：属于刑法的兜底条款，使用同类解释规则解释——手段性质上面和前四种罪行相同（严重危及人身安全，属于暴力犯罪）
6. 暴力侵害ing——暴力侵害已结束不能适用本款规定

【必考】 【论述】 防卫过当和无过当防卫的关系与区分——是不是只有严重危及人身安全才能使用特殊防卫？

（不法侵害人没有实施严重危及人身安全但是被害人致其死亡算是防卫过当？）

防卫程度性的要求不是唯结果论，而是在前端防卫手段和不法侵害行为产生大致相当性即可认定正当防卫，即使结果超出也不认定为过当。总体上，只有手段和结果同时超出才算做过当，否则算作一般防卫。

紧急避险 **【3卷】**

1. 紧急避险的概念（《刑法》第20条）

第20条 [紧急避险] 为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在发生的危险，不得已采取的紧急避险行为，造成损害的，不负刑事责任。

[避险过当] 紧急避险超过必要限度造成不应有的损害的，应当负刑事责任，但是应当减轻或者免除处罚。

[避险禁止] 第一款中关于避免本人危险的规定，不适用于职务上、业务上负有特定责任的人。

2. 紧急避险的构成要件

- (1) 避险意图：须出于保护合法权益的目的
- (2) 避险起因：合法权益遭遇现实危险
- (3) 避险时间：现实危险正在发生
- (4) 避险对象：第三者的合法权益
- (5) 避险限度：没有超过必要限度
- (6) 避险限制：只能出于迫不得已
- (7) 避险禁止：不适用于负有特定职责之人

3. 紧急避险的类型

以避险对象为依据：

- (1) 攻击型紧急避险（针对无辜第三人）
- (2) 防御型紧急避险（针对危险制造者）

第十一章 故意犯罪的停止形态

1. 犯罪既遂 (myx笔记) 【必考】

概念：行为人故意实施的犯罪行为已经具备了刑法分则规定的该种犯罪构成的全部要件，也就是已经达到犯罪的完成状态

1. 结果犯 & 行为犯 —— 判断犯罪的既未遂

(1) **结果犯**：不仅要实施具体犯罪构成要件的行为，而且必须发生法定的犯罪结果才构成既遂的犯罪

除了实施刑法分则条文规定的客观方面的行为以外，还必须发生法定的危害结果才能成立犯罪既遂的犯罪形态。如果法定危害结果没有发生，则成立未完成形态。**故意杀人罪**

【注意】

a. 必须是有形的，可以计量的物质性损害结果

b. 其次，这种危害结果必须与犯罪的性质相一致，而不是指犯罪行为给犯罪对象所造成的任何物质性损害结果

* 该结果只要符合相应犯罪构成要件即可，不需要考虑是否为行为人所追求的结果

(2) **行为犯**：指以法定的犯罪行为的完成作为既遂标志的犯罪。

虽不需要发生某种危害结果，但要求危害行为实施到一定程度才构成犯罪既遂的犯罪形态 **诬告罪**

行为犯包含举动犯、程度犯和危险犯；对应结果犯

【问题】对于行为犯，一旦实施就成立既遂，则若行为人有意补救也作用甚微？（如**放火罪**，窗帘点着立刻扑灭也基本无济于事？）

行为犯危害行为的完成需要一个时间过程，要达到一定的程度。只有危害行为达到法律所要求的程度，犯罪既遂才能成立。如**脱逃罪**必须达到脱离被关押的程度才认为是犯罪既遂。如果危害行为在达到法律要求的程度之前停止下来，只能成立犯罪未遂或者其它未完成形态。

2. 危险犯 & 实害犯 —— 判断是否成立犯罪

(1) **危险犯**：以行为人实施的危害行为造成法律规定的发生某种危害结果的危险状态作为既遂的标志

危害行为和危害行为所造成的危险状态共同构成犯罪客观方面完整性的犯罪。

（危险出现犯罪就可以成立）**危险驾驶罪**（但是目前已经由抽象危险犯转入具体危险犯）✓

★ 注意：是“成立”犯罪，不是犯罪“既遂”

a. **抽象危险犯**：危险是有法律推定的，只有发生即可认定，不属于构成要件，不需要法官（广义法官，指司法工作人员）判断

b. **具体危险犯**：属于构成要素，法官需要结合事实判断

【讨论】分具体危险犯和抽象危险犯的意义（可能考）【论述】

抽象危险犯中的危险是由法律推定的，只要发生即可认定，不属于构成要件，不需要法官（广义法官，指司法工作人员）判断

具体危险犯：属于构成要素，法官需要结合事实判断

ex1：醉驾已经成为具体危险犯——原先是血液中酒精达到80毫克就定罪量刑（抽象危险犯），但是目前不仅需要达到80毫克，还需要法官结合案发当时是否实际地对公共安全造成侵害（具体危险犯）。

【注意】

如果把危险状态视为一种非实害性的结果，危险犯也是一种结果犯。

有的危害行为一经实施危险状态即行存在，这种危险犯类似于举动犯。

有的危险行为实施后并不能造成实际的危险，这种危险犯就不是既遂。对于危险犯而言，**危害行为**和**危险状态**同时具备才具有完整性，且危险状态是与危害行为的性质相一致的，所以，危险犯的既遂应以二者同时具备为标志。

(2) **实害犯**：只有危害结果出现，才成立犯罪

过失致人死亡罪：只有死亡结果出现了，才认为违反了注意义务，构成罪名

3. **举动犯**：犯罪一经着手实施其客观方面的要件即告完整或齐备的犯罪。

煽动分裂国家罪、煽动民族仇恨罪

【区别】举动犯 vs 行为犯

行为犯的行为如果没有完成，其客观方面还不具备完整性，因而还可能成立未遂。而举动犯只要着手实行，其客观方面即具备完整性，从这个意义上讲，举动犯无所谓既遂、未遂之分。

通说认为**确立举动犯的原因在于某些犯罪危害性严重**，例如**参加恐怖活动组织罪**，或者某些犯罪行为性质特殊，例如**教唆煽动性质的犯罪**，在一举动时就认为既遂可以更加有效地防范和打击这些犯罪。

2. 各个停止形态的定义+构成要件+量刑 【必考】

(1) 犯罪预备：指行为人为了实行犯罪，准备工具，制造条件，但由于行为人意志以外的原因尚未着手实行的犯罪形态。

【要件】

① 客观特征：实施了准备工具、制造条件的行为

→ “准备工具”：包括**购买、制造、编造、转借工具**

→ “制造条件”：除了准备工具外的其他准备活动 **实现察看现场、选择犯罪时机、排除犯罪障碍、探听被害人行踪、演习犯罪场景、拟定犯罪计划、寻找和勾结同伙等**

② 主观方面：行为人的目的是为了实行犯罪

③ 行为人没有着手实行犯罪

④ 犯罪行为停留在预备阶段是由于行为人意志以外的原因

【刑事责任】对于预备犯，可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。

(2) 犯罪未遂★ ★ ★ 【必考】：已经着手实行犯罪，由于犯罪分子**意志以外的原因而未得逞的**，是犯罪未遂。

【要件】

① 行为人已经着手实施犯罪

→“着手”判定：**中间行为说**——看要不要再实施另一个行为才能发生危害结果

② 犯罪未得逞

→“未得逞”含义：犯罪构成的要件没有齐备（不是主观上的犯罪目的没有实现）

③ 犯罪未得逞是由于行为人意志以外的原因

→“意志以外”：指行为人没有预料到或者不能控制的主客观原因 如个人能力、认识错误、被害人反抗、第三人的阻止、自然力的阻碍

【刑事责任】对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。

(3) 犯罪中止：在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的，是犯罪中止。

【要件】

① 必须发生在犯罪过程中

② 行为人必须主观上有中止犯罪的决意

→“中止犯罪的决议”：行为人自认为在客观上能够继续犯罪和实现犯罪的情况下，自动做出的不继续犯罪或者不追求犯罪结果的选择（在“惧怕刑罚的危险而停手情”景下的简化：判断惧怕刑罚的危险是现实性的还是将来性的——现实性的就是未遂；未来性的才是中止——危险是否变得现实、急迫、高概率“躲无可躲”）

★ 犯罪中止的成立不考虑动机的高尚/卑劣 【必考】

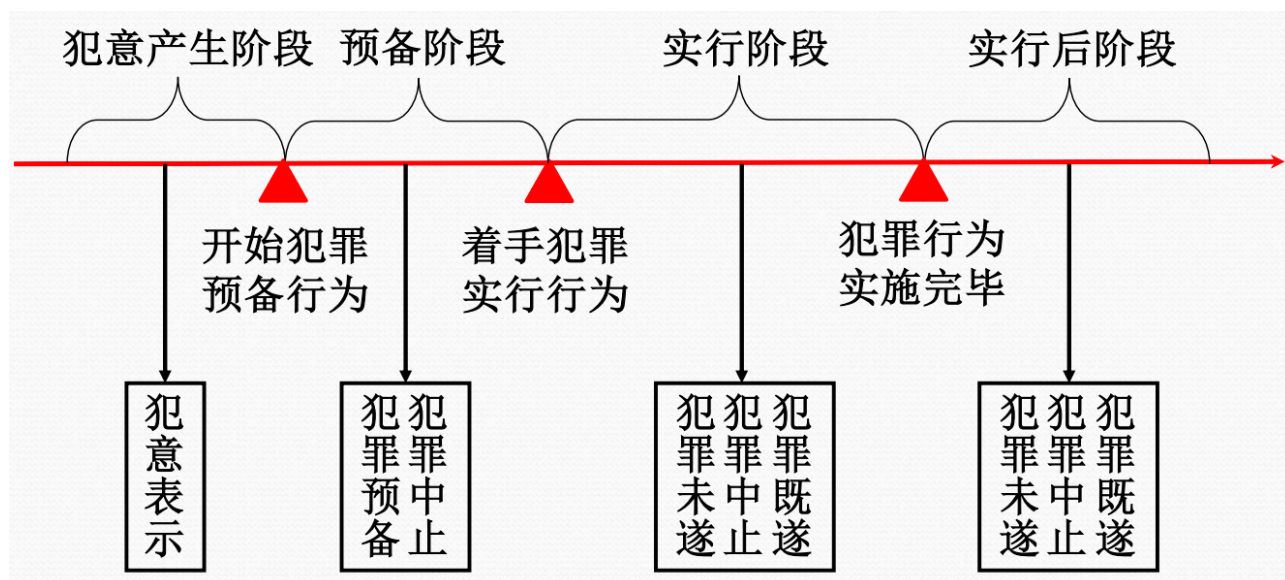
【判断方法】“不合理决断说”：认定犯罪未遂还是中止的关键在于判断标准，认定中止必须有严格限制，即放弃犯罪的举动是基于心中的不合理决断（即客观上保护了被害人的法益）。（合理决断：有利于自己的决定；不合理决断：客观对自己不利但是对于被害人的法益保护有利）

③ 行为人客观上实施了中止犯罪的行为

④ 犯罪中止必须是有效的

【刑事责任】对于中止犯，没有造成损害的，应当免除处罚，造成损害的，应当减轻处罚。

3. 各个犯罪停止形态对比 【必考】



★ 注意：到某一个点，某一个点具有不可回溯性，停止形态彼此之间互相排斥

(1) 【区别】犯罪预备 & 犯罪未遂

犯罪预备事实上没有着手实行犯罪，即未能实施刑法分则规定的犯罪构成要件所包含的实行行为；犯罪未遂则是部分但没有完全满足犯罪的构成要件

(2) 【区别】犯罪预备 & 犯罪中止

犯罪预备中犯罪行为停留在预备阶段是由于行为人意志以外的原因；犯罪中止是行为人主观上有中止犯罪的决意

【总结】犯罪样态的区分 【必考】 【论述】

(1) 停顿阶段不一样：犯罪预备只能停留于犯罪的预备阶段，犯罪的未遂只能停留在实行阶段，犯罪的中止既可以又可以

(2) 停顿原因不一样：犯罪预备和未遂都是客观原因导致结果没有出现，犯罪中止则是主观原因导致的

(3) 法律后果不一样：三者从宽处罚的幅度不同

3. 犯罪中止分类

(1) 自动停止型犯罪中止特征

① 时间性：必须在犯罪过程中停止犯罪，包括犯罪预备阶段和犯罪实行阶段

② 自动性：必须自动停止犯罪行为，即行为人自认为在客观上能够继续犯罪和实现犯罪的情况下，自动做出的不继续犯罪或者不追求犯罪结果的选择

③ 彻底性：行为人彻底放弃了原来的犯罪

(2) 结果防止型犯罪中止特征

① 时间性：只能发生于犯罪行为实行终了之后、犯罪结果发生之前

② 自动性：行为人仅仅以消极方式停止不够，还必须采取积极的措施防止犯罪结果的发生

③ 有效性：行为人的行动不仅要积极，还需要有效地防止犯罪结果的发生。

(犯罪结果成立则不具备有效性)

④ 彻底性

【区别】自动停止型犯罪中止 & 结果防止型犯罪中止

(1) 时间性：二者时间界限不同——前者是在实行行为终了前自动中止的；后者是在犯罪行为实行终了之后，犯罪结果发生之前。

(2) 自动性：前者行为人自动停止犯罪行为即可；后者仅仅以消极方式停止不够还必须采取积极的措施防止犯罪结果的发生

(3) 有效性：后者行为人的行为必须有效地防止犯罪结果的发生

【联系】

(4) 彻底性：行为人都彻底放弃了原来的犯罪

4. 犯罪中止的特别成立：自动放弃重复侵害行为 (必考)

5. 部分情景下的分析 (myx 笔记)

【讨论】存在轻微不利的场合，行为人放弃犯罪，究竟是自动还是被迫，可根据以下情况处理：

- 【简化】判断惧怕刑罚的危险是现实性的还是将来性的——现实性的就是未遂；未来性的才是中止（危险是否变得现实、急迫、高概率“躲无可躲”）

【讨论】多个因素存在情况下（如主观决定不实施+客观手段不能犯）成立中止还是未遂？

核心：看结果不发生的直接原因

【学说】判断是中止还是未遂：（日本学者）“不合理决断说”

【不合理决断说】：认定犯罪未遂还是中止的关键在于判断标准，认定中止必须有严格限制，即放弃犯罪的举动是基于心中的不合理决断（即客观上保护了被害人的法益）。（合理决断：有利于自己的决定；不合理决断：客观对自己不利但是对于被害人的法益保护有利）

注意：需要结合实际情况对行为人主观内心进行把握（综合考量）

★★结合共同犯罪★★

5. 共同犯罪的犯罪形态（必考）

1. 共同正犯：（简单共同犯罪—没有分工）全体共同犯罪人都是实行犯

按照部分实行全体负责的原则加以解决。

2. 在复杂共犯场合，教唆犯和帮助犯从属于正犯

（1）正犯既遂或者未遂的，教唆犯和帮助犯也是既遂或者未遂（原则上，按照正犯故意犯罪停止形态认定共犯）

（2）帮助犯犯罪阶段的确定从属于正犯，即正犯在处于犯罪预备阶段的，则帮助犯也处于预备阶段。

但是教唆犯阶段的确定具有独立性。

【结论】

① 正犯是犯罪预备犯，帮助犯是预备犯，教唆犯是犯罪未遂

② 正犯成立预备阶段的中止时，帮助犯是犯罪预备，教唆犯是犯罪未遂

③ 正犯成立实施阶段的中止，帮助犯和教唆犯均为犯罪未遂

3. 犯罪中止（共犯脱离问题）

共同犯罪人一致自动放弃犯罪的，是犯罪中止

共犯脱离必须有效的阻止犯罪的实施——若脱离之后犯罪没有继续下去，成立犯罪中止；若脱离之后没有满足有效性的要求，根据其他正犯的停止形态确定

4. 犯罪中止（特别实现）（必考）

自动放弃重复侵害行为成立犯罪中止——谁中止谁受益则：

对于其他人属于个体意志之外的情况，成立犯罪未遂

对于自动放弃重复侵害行为的行为人，成立犯罪中止

第十二章 共同犯罪

1. 共同犯罪的概念和要件

指二人以上共同故意犯罪

(1) 主体要件：必须是两个以上的人（包括单位和自然人「扩大解释」）

★ 注意：单位设立之初就是为了犯罪，则不认定为单位。认定为犯罪团伙/集团

(2) 客观要件：行为

必须有共同犯罪的行为。各共同犯罪人的行为结成了一个整体，互相联系，共同配合，共同导致了危害结果的发生。

→ 共同犯罪的行为：① 共同行为指向那个相同的保护客体（法益）② 共同行为是犯罪发生的原因

(3) 主观要件：故意

指各共同犯罪人通过意思联络，认识到他们的行为会发生危害社会的结果，并且希望或者放任该结果的发生。

→ 共同故意

① 原则：必须有双向的共同故意，即犯意联络

【例外】片面共犯：单向的犯意联络，但是也属于共同犯罪

② 形成时间：事前或者事中，不能是事后（既遂）

③ 形式：一般都是通过明显的语言形成，但在临时起意的场合，一方明知另一方在实行犯罪，但是采取容忍的态度，尽管没有亲手实行，也成立共同犯罪。

【情形】缺乏共同故意而不构成共同犯罪情况（分别论处）：（必考）

① 共同过失犯罪

② 一方故意一方过失

③ 同时犯：双方在相同或者相近的时间地点实施了性质相似的举动，无犯意的联络——【法定】（证据法上的困难导致）疑罪从轻，如若既遂则定为未遂

④ 先后犯：双方前后有间接续，但是没有犯意联络

⑤ 实行过限：超出共同犯罪意思的谋划，单独的产生一个独有的犯意——谁过限谁负责，其他人不对过限的部分负责（罪责自负机理：主客观相统一）

2. 共同犯罪中秉持的分析理论：成立部分犯罪共同说，但是在具体处罚阶段实施罪责自负（myx笔记）

(1) 确定“共同”犯罪：

「部分犯罪共同说」行为和犯意有一部分的重合【学界·通说】

(2) 共犯处罚依据：

① 「因果共犯论」狭义共犯实施的举动对实行犯在因果流程上有促进作用。

（放宽的因果共犯论）也包含心理上因果的贡献，如强化犯罪意图

→ 推论：（成立共犯脱离的条件）消极的退出并不能构成犯罪中止，必须用一些积极的举动将前期制造出的危险消除（**犯罪中止中，已经造成危险时，必须采取一些反制的举动**）

②「共犯的从属性—限制从属性说」共犯受到处罚的前提是正犯的行为成立犯罪。【通说】——处罚的从属性是狭义的共犯从属于正犯，但是罪责自负

四要件漏洞：正犯未达到刑事责任年龄时，不构成违法；进而从犯若已经达到刑事责任年龄，也不违法。则此处存在处罚漏洞。

三阶层按照犯罪论体系的处理：成立共同犯罪以实行犯的行为具备构成要件符合性和违法行为（形式不法）前提。进而分别分析正犯和从犯，罪责自负

3. 【分析流程】共同犯罪案例分析 【案例分析】

先大概判断是共同犯罪（人数）：

- (1) 先分析**实行犯**：罪名认定
- (2) 再分析**狭义的共犯**（教唆犯、帮助犯）

4. 共同犯罪的犯罪形态（必考）

1. 共同正犯：（简单共同犯罪—没有分工）全体共同犯罪人都是实行犯

按照**部分实行全体负责的原则**加以解决。

2. 在复杂共犯场合，教唆犯和帮助犯从属于正犯

(1) 正犯既遂或者未遂的，教唆犯和帮助犯也是既遂或者未遂（**原则上，按照正犯故意犯罪停止形态认定共犯**）

(2) **帮助犯犯罪阶段的确定从属于正犯**，即正犯在处于犯罪预备阶段的，则帮助犯也处于预备阶段。

但是**教唆犯阶段的确定具有独立性**。

【结论】

- ① 正犯是犯罪预备犯，帮助犯是预备犯，教唆犯是犯罪未遂
- ② 正犯成立预备阶段的中止时，帮助犯是犯罪预备，教唆犯是犯罪未遂
- ③ 正犯成立实施阶段的中止，帮助犯和教唆犯均为犯罪未遂

3. 犯罪中止（共犯脱离问题）

共同犯罪人一致自动放弃犯罪的，是犯罪中止

共犯脱离必须**有效的阻止犯罪的实施**——若脱离之后犯罪没有继续下去，成立犯罪中止；若脱离之后没有满足有效性的要求，根据其他正犯的停止形态确定

4. 犯罪中止（特别实现）（必考）

自动放弃重复侵害行为成立犯罪中止——谁中止谁受益则：

对于其他人属于个体意志之外的情况，成立犯罪未遂

对于自动放弃重复侵害行为的行为人，成立犯罪中止

5. 共同犯罪人的种类——主犯

- (1) 相关概念（背）

主犯：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯

首要分子：指在犯罪集团或者聚众犯罪中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子

(2) 分类

- ① 犯罪集团中的首要分子
- ② 聚众共同犯罪中的首要分子
- ③ 其他在共同犯罪中起主要作用的犯罪分子

【区别】主犯 vs 首要分子 (必考) 【论述】

主犯：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。首要分子：指在犯罪集团或者聚众犯罪中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子

由上概念可得：主犯不一定是首要分子；首要分子不一定是主犯。具体区别如下：

(1) 发生的场合不同：首要分子只存在于犯罪集团和聚众中，而主犯既可以存在于犯罪集团和聚众犯罪中，又可以存在于一般共同犯罪中

(2) 主犯包含犯罪集团中的首要分子，还包含其他共同犯罪中起主要作用的犯罪分子

(3) 犯罪集团中的首要分子都是主犯，但是聚众犯罪的首要分子不一定。比如在具有个别可罚性的聚众犯罪中，首要分子若为一人，就不能成立共同犯罪，当然也就不存在主犯问题。

6. 共同犯罪人的种类——从犯

分类：

- ① 在共同犯罪中起次要作用的人员，即次要的实行犯
- ② 在共同犯罪中起辅助作用的人员，即帮助犯

7. 共同犯罪人的种类——教唆犯 (必考·必背)

(1) 概念：教唆他人犯罪的，是教唆犯

(2) 刑事责任：

第二十九条 教唆他人犯罪的，应当按照他在共同犯罪中所起的作用处罚。教唆不满十八周岁的人犯罪的，应当从重处罚。

如果被教唆的人没有犯被教唆的罪，对于教唆犯，可以从轻或者减轻处罚。

(未免除)

【详细🔍】

1. 教唆他人犯罪的，应按其在共同犯罪中的作用处罚。教唆犯可以是主犯、从犯，但不能是胁从犯

2. 教唆不满18周岁的人犯罪的，对教唆犯从重处罚。具体包括：

- (1) 教唆已满16周岁不满18周岁的人实施任何罪行的
- (2) 教唆已满14周岁不满16周岁的人实施特定的8种罪行的；教唆已满12周岁不满14周岁的人实施特定情节的故意杀人、故意伤害行为的
- (3) 【间接正犯】教唆已满14周岁不满16周岁的人实施8种特定罪行以外的其他罪行的；教唆已满12周岁不满14周岁的人实施特定情节的故意杀人、故意伤害行为以外的其他罪行的；教唆不满12周岁的人实施任何罪行的

3. 被教唆人没有犯被教唆之罪的，对教唆犯可以从轻或者减轻处罚。这种情况在刑法理论上被称为**教唆未遂**，即教唆行为没有引发相应的危害结果。具体包括：

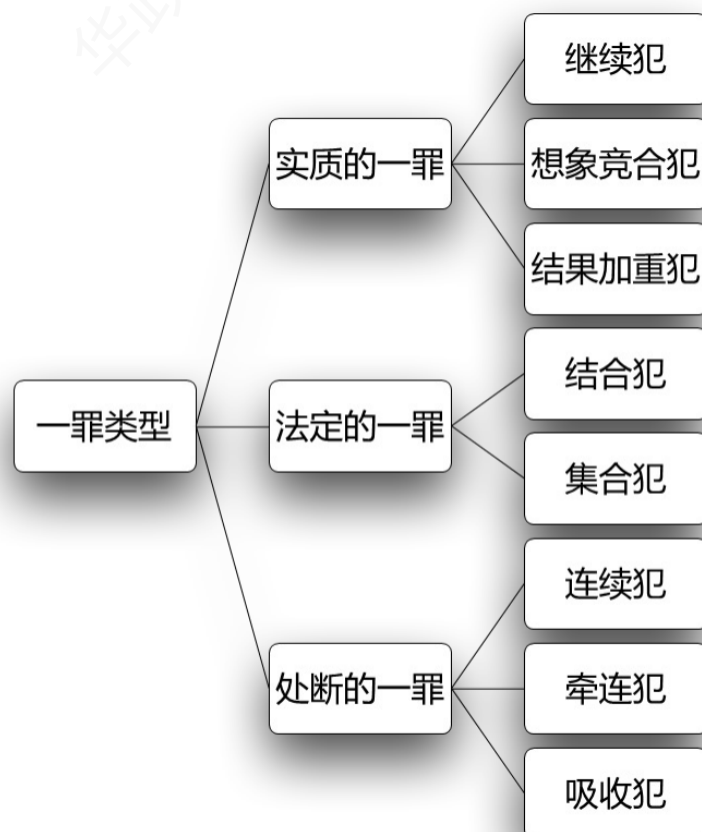
- (1) 拒绝教唆
 - (2) 当时接受了教唆，但事后又打消了犯罪意图，没有进行任何犯罪活动
 - (3) 接受了教唆，但事后实施了其他犯罪行为，没有实施所教唆之罪
 - (4) 对方已经有犯罪意图，误以为其没有犯罪意图而对其进行教唆（对象不能犯）
4. 【例外】部分共同犯罪中的教唆犯：如**甲教唆乙盗窃，乙转化为抢劫的**。教唆犯与被教唆犯在犯罪性质重合的部分成立共同犯罪，对教唆犯不适用第29条第2款的规定

第十章 罪数形态

【基础理论-处理原则·通说】

(1) 行为人只实施了一个行为，通常认定为一个犯罪，哪怕这个行为同时触犯了多个罪名（**一个行为只能认定为一罪**）；两个以上行为也要看刑法具体规定。

(2) 多个行为评价的两大原则：①基于保护法益的需要，要对所有关键的涉及犯罪构成的构成要件要素**全面评价**，不可遗漏②基于被告人保护（人权保障），**禁止重复评价**（行为、目的、主观）



一、单纯的一罪（典型的一罪）

（一）纯粹的一罪

刑法上将一个犯罪构成规定为一罪

（二）选择的一罪

刑法条文上规定了若干独立的犯罪构成，既可以由一个犯罪构成成立一罪，也可以由两个或者两个以上的犯罪构成成立一罪

生产、销售伪劣产品罪；非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪（★刑法上带“、”的罪名一般是选择性罪名——行为人实施几个就定几个）

（三）复合的一罪

两个或两个以上的法定犯罪构成成立一罪

绑架罪、抢劫罪、强奸罪

二、特殊一罪的类型

（一）实质的一罪（形式数罪、实质一罪）

1. 继续犯

也称持续犯，指作用于同一对象的一个犯罪行为从着手实行到行为终了，犯罪行为与不法状态在一定时间内同时处于继续状态的犯罪。

（行为+行为所造成的状态同时处于继续）

（1）要件：

- ① 基于一个犯罪故意实施一个犯罪行为
- ② 持续作用于同一对象，侵害同一法益
- ③ 犯罪行为与不法状态同时继续
- ④ 从着手到行为终了继续一定时间

（2）法律效果

① 追诉时效是从行为开始实施计算还是行为已经结束计算？——追诉时效根据行为已经结束计算

② 对于既未遂的影响？——继续犯的持续时间长短会影响既未遂的认定

③ 影响正当防卫——行为结束但是行为创造的危险还在继续，属于不法侵害正在发生，仍然属于正当防卫时间范畴

④ 影响共同犯罪的成立——成立承继的共犯（均为正犯）；罪责仍为自负

事中的共犯（承继的共犯）（要求其他行为人已经着手实施了犯罪的行为，而某些行为人基于犯罪意思又加入了犯罪的行列）

一般认为犯罪已经既遂（事后），其他人就无法加入再成立共同犯罪。但是该原则在承继的共犯有所突破，因为犯罪行为和犯罪所存在的状态事实上依然继续。绑架罪索财的行为不影响绑架罪的认定，一旦有非法拘禁的绑架行为（无论索要财物为目的）立刻成立绑架罪【短缩的二行为犯】。且绑架+索财行为两个行为也只成立绑架罪一罪。

（3）存在范围——判断是否属于继续犯

① 侵害人身类 绑架、非法拘禁

② 非法持有类

③ 不作为犯（用于处理实践中棘手的问题）建筑商建筑过程偷工减料，楼设计寿命为70年，其实际应当只能乘30年，楼最终在35年倒下，远超诉讼时效。——建筑的状态所形成的情形依然处于持续过程中，且属于一个重大的法益。则对于行为所造成的状态有一个阻止其变为现实的义务。（实际不是继续犯，而是状态犯。状态犯一般不做处罚，但是此处特事特办）

(4) 【特殊】特殊处理

张思睿过十二周岁生日当天给李菲儿投毒，结果李菲儿第三天才去吃有毒的食品，最终毒发身亡，张思睿的行为能不能加以处罚？（行为时候没有刑事责任年龄，第三天有了，那要不要他解除该状态？）——【通说】有解除义务，成立故意杀人罪。

○ 处断：定一罪

【区别】继续犯与状态犯、即成犯的区别

继续犯：行为和状态同时继续

状态犯：只有状态继续，行为已经结束

即成犯：行为和状态在实施完后就结束，状态不会持续

2. 想象竞合犯（必考）

指行为人基于一个犯罪意图支配下的数个罪过，实施一个危害行为，同时触犯数个罪名的犯罪形态。

张思睿想打李菲儿，开枪后子弹擦过李菲儿手臂将后面的人打死。——一个开枪的行为造成一伤一死两个结果→若张思睿对于后面李菲儿的突然冒头没有意识到，一般认为张思睿构成过失致人死亡，则此时构成故意杀人的未遂+过失致人死亡想象竞合，从一重罪处断。（一个行为只能定一罪，但是此处存在两个法益被侵害故从一重罪处断）

特点：

(1) 实质一罪

(2) 因造成数个不同的结果而在形式上符合数罪

○ 处断：从一重罪定罪（结合具体案情考虑哪一个更重，被吸收的罪需要被考虑进量刑）

【区别·争议】与法条竞合的区别 【（可能）论述/案例】

——核心：坚持全面评价+禁止重复评价

法条竞合中 看一个罪名能否实现对另一个罪名的包容

想象竞合中 要素有交叉，但是无法包容

（陈兴良教授）法条竞合：特别关系、补充关系、包容关系

（张明楷教授）法条竞合：不应该根据要素，而是应该根据侵害的法益是否相同——法益相同为法条竞合，法益不同的为想象竞合

【区别】打击错误&想象竞合犯

事实认识错误：一个行为，一个结果

3. 法条竞合

核心：看一个罪名能否实现对另一个罪名的包容

(1) 概念：一行为同时符合刑法分则规定的数个罪名，在裁判上只能适用某一罪名，而排斥其他法条的适用。

(2) 种类

(陈兴良教授) 法条竞合：特别关系、补充关系、包容关系

(张明楷教授) 法条竞合：不应该根据要素，而是应该根据侵害的法益是否相同——法益相同为法条竞合，法益不同的为想象竞合

A. **特别关系** 如**诈骗罪与各类金融诈骗罪、合同诈骗罪**

○ 处理原则：**特别法优于一般法**

【例外】重法优于轻法

① 生产、销售伪劣产品罪 VS 生产、销售特定产品罪

② 诈骗罪 VS 招摇撞骗罪

③ 诈骗罪 VS 冒充军人招摇撞骗罪

④ 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 VS 洗钱罪

B. **补充关系** 如**走私普通货物、物品罪与走私淫秽物品罪、走私武器、弹药罪**

○ 处理原则：**辅助法条优于基本法条**

C. **包容关系** 指一罪的外延是另一罪外延的一部分

○ 处理原则：**全部法、完全法优于部分法、不完全法**

① 放火等以危险方法危害公共安全的犯罪在导致被害人死亡时，包容故意杀人、故意伤害罪

② 绑架罪包容故意杀人罪、过失致人死亡罪

③ 拐卖妇女罪包容强奸罪

④ 拐卖妇女罪包容引诱、强迫卖淫罪

⑤ 抢劫罪包容故意杀人罪、故意伤害罪

⑥ 组织、运送他人偷越国边境罪以及走私、贩卖、运输、制造毒品罪包容妨害公务罪

【案例·“小区撞人案”】（张明楷教授用新的法条竞合分类 意图解决处罚漏洞）张思睿开车进入某小区，意欲拜访李菲儿。该小区允许外部车辆收费停车。因找不到楼号，张思睿停车询问路边的一位大妈。大妈告诉他走过了路，张思睿遂倒车，不慎将跑到车底捡皮球的4岁小孩李赋压成重伤。张思睿停车报案。问：张思睿的行为如何定性？

交通肇事致一人以上重伤，负事故全部或者主要责任，并具有下列情形之一的，以交通肇事罪定罪处罚：

- (一) 酒后、吸食毒品后驾驶机动车辆的；
- (二) 无驾驶资格驾驶机动车辆的；
- (三) 明知是安全装置不全或者安全机件失灵的；
- (四) 明知是无牌照或者已报废的机动车辆而驾驶的；
- (五) 严重超载驾驶的；
- (六) 为逃避法律追究逃离现场的。

——交通肇事不构成犯罪+过失致人重伤罪 【通说】认为属于法条竞合，立法有专门对交通肇事的情况加以规定，所以最终只能适用交通肇事罪。

→问题：（张明楷教授）道路上就可能不构成犯罪，而在封闭的道路上又变成了过失致人重伤？——必须要满足罪行均衡原则。所以此处的分析应该为：交通肇事罪保护的法益是公共交通安全，过失致人重伤保护的是人身财产利益，二者侵害法益不同，为想象竞合，从一重，则为过失致人重伤罪。

→问题：违背了罪刑法定原则。【通说】在罪刑法定和罪行均衡原则相冲突时，应优先适用罪刑法定。

4. 结果加重犯

指实施基本犯罪构成要件的行为，发生基本犯罪构成要件以外的重结果，因而刑法规定加重处罚的形态。

（行为人实施了一个基本的犯罪行为，但该犯罪行为却因果性地引发了较重的犯罪结果）抢劫致人重伤或者死亡

要件：

（1）实施基本犯罪构成要件的行为

（2）产生了基本犯罪构成要件以外的重结果——具备因果关联性

【问题】没有因果关联性，构不构成结果加重犯呢？——不构成。判定：按照一般人角度，看是否存在合理性（张明楷教授：否则成立缓和的结果归属，按照生活意义上的因果关联性）

（3）心态：一般为过失，个别为故意 故意伤害致人死亡

★注意：特殊情况下，以较重犯罪结果为目的实施基本犯罪行为，只构成前面一罪。以故意杀人为目的的抢劫只定成抢劫罪。

一般情况下，行为人构成结果的加重均为过失，而不是故意。因此才区分了故意伤害致人死亡和故意杀人罪

★注意：犯罪意图出现的先后会影响定性。若抢劫已经实施完毕，后面又想去杀人灭口，此时则构成抢劫罪+故意杀人罪。

○处断：定一罪，加重处罚

★注意：基本犯必须是结果犯，且主观方面只能是故意

（二）法定的一罪

1. 结合犯 A罪+B罪=AB罪

指数个各自独立的犯罪行为，根据刑法的明文规定，结合而成为另一个独立的新罪的形态。

（1）所犯数罪原为数个独立的犯罪

（2）结合成另一个独立的新罪

（3）旧罪失去独立意义，成为新罪的一部分

（4）刑法明文规定结合

○处断：依照刑法规定的新罪定罪

「我国变种结合犯」A罪+B罪=C罪，C罪具备A罪、B罪要素但是并不周严

Ex1: 《刑法》第269条：犯盗窃、诈骗、抢夺罪，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭证据而当场使用暴力或者以暴力相威胁的，依照本法第263条（抢劫罪）定罪处罚。

盗窃、诈骗、抢夺罪+故意伤害罪=抢劫罪

2. 集合犯

指行为人以实施不定次数的同种犯罪行为为目的，虽然实施了数个同种犯罪行为，刑法规定还是作为一罪论处的形态。

（法定一罪但是多个行为举动）

成立要件：

- (1) 以实施不定次数的同种犯罪行为为目的
- (2) 实施了数个同种犯罪行为
- (3) 刑法规定为一罪

种类：常业犯（如非法行医）、营业犯（如赌博为业的赌博罪）

○ 处断：以**法定的一罪定罪**

3. 转化犯

指在实施一个较轻之罪的过程中连带地触犯了另一个较重之罪的情形。转化犯是刑法明文规定的，应按一罪处理，即按照转化后的重罪处理。

对于转化犯，应当特别注意**转化条件**的问题。

我国刑法中的转化犯主要包括：

- (1) 非法拘禁罪转化为故意伤害、故意杀人罪（第238条第3款，注意必须是使用暴力致人伤残、死亡）
 - (2) 收买被拐卖的妇女、儿童罪转化为拐卖妇女、儿童罪（第241条第5款：收买后又出卖）
 - (3) 刑讯逼供罪、暴力取证罪转化为故意伤害罪、故意杀人罪（第247条，对伤害、死亡结果必须是故意的，注意是从重处罚）
 - (4) 虐待被监管人罪转化为故意伤害、故意杀人罪（T248，对伤害、死亡结果必须是故意的，注意是从重处罚）
 - (5) 抢夺罪转化为抢劫罪（第267条第2款，携带凶器抢夺）；
 - (6) 盗窃、诈骗、抢夺转化为抢劫（T269）
 - (7) 聚众斗殴罪转化为故意伤害罪、故意杀人罪（T292K2：对伤害、死亡结果必须是故意）
 - (8) 非法组织卖血罪、强迫卖血罪转化为故意伤害罪（T333K2故意造成重伤、死亡结果）
 - (9) 非法提供麻醉药品、精神药品罪转化为贩卖毒品罪（T355K1：向走私、贩卖毒品的犯罪分子或者以牟利为目的，向吸食、注射毒品的犯罪分子提供国家规定管制的能够使人形成瘾癖的麻醉药品、精神药品）
 - (10) 挪用公款罪转化为贪污罪（T384携带挪用的公款潜逃；挪用公款后采用虚假发票平账、毁账且不归还原；截取单位收入不入账且不归还原；有能力归还而拒不归还并隐瞒公款去向。如果仅因客观原因不能归还，仍然定挪用公款罪）
- 理论上还存在着两种常见的转化犯，即妨害公务、抗税等犯罪活动中使用暴力故意致人重伤死亡的，按故意伤害罪、故意杀人罪处理。

【区别】转化罪 & 犯意转化

转化犯：一个罪名转化成另一罪名进行处理，需要刑法的特别规定

犯意转化：行为人在着手之前的行为意图发生了变化

(三) 处断的一罪**1. 连续犯**

指行为人基于同一或概括的犯罪故意，连续多次实施数个同一性质的犯罪行为，依法以一罪论处的形态。

(基于同一概括的故意，多次的实施同一性质的犯罪——**多个举动**)

- (1) 客观方面实施了数个**同一性质**的犯罪
- (2) 主观方面基于**同一或概括**的犯罪故意
- (3) 数个行为之间具有**连续性**
- (4) 数行为**触犯同一罪名**

○ 处断：定**一罪**；属于**从重处罚情节的则依法从重**处罚

多次盗窃，按照盗窃罪定性。同时将一年中盗窃的数额累加来看处罚情节。

【区别】连续犯 & 继续犯——多个/一个举动

2. 牵连犯 (部分学者：没有必要)

指以实施某一犯罪为目的，其方法行为或结果行为又牵连触犯其他罪名的形态。(要素之间具有**继发性**)

要件：

- (1) 以实施一个犯罪为目的
- (2) 必须有两个以上的行为
- (3) 数个行为之间具有牵连关系
- (4) 数个行为触犯了不同罪名

○ 处断：**以一重罪定罪 (真正：完全按照刑法分则的规定，没有也是数罪并罚)**

★ 注意：法律明确规定数罪并罚的，依法律规定。

为了骗保而杀人——**刑法规定数罪并罚**

3. 吸收犯 (部分学者：没有必要)

指数个犯罪行为，其中一个犯罪行为被另一个犯罪行为吸收，仅定吸收之罪的形态。

- (1) 具有数个犯罪行为
- (2) 数行为必须触犯不同罪名
- (3) 数个行为之间具有吸收关系

表现：重行为吸收轻行为；实行行为吸收预备行为；

主行为吸收从行为；正犯行为吸收共犯行为。

○ 处断：**依照吸收行为定罪**

谋财害命：故意杀人吸收谋财

★ 例外：共罚的事后行为

张思睿盗窃李菲儿的貂皮大衣，后来觉得是假的于是将其烧了。事后查明是真的。——此时成立共罚的事后行为，因为主观上不知道其价值不成立故意损害财物罪。

【变式】即使事后是故意烧掉的，但是从盗窃一直到烧都处于一个损害财物的状态，没有必要对故意损害财物单独评价，所以也属于共罚的事后行为。

第十六章 刑罚的体系和种类

★主刑★

1. 死刑

1. 概念

是剥夺犯罪人生命的刑罚方法，也称**极刑**。

2. 死刑的适用原则★：**限制死刑的适用**

(1) 适用条件的限制：**罪行极其严重**

(2) 适用对象的限制

① 犯罪时未满18周岁的未成年人

② 审判时怀孕的妇女

③ 审判时已满75周岁的老年人（手段极其残忍的除外）

(3) 适用程序的限制：**死刑复核程序**

(4) 执行制度的限制：**死缓制度**

对于应当判处死刑的犯罪分子，如果不是必须立即执行的，可以判处死刑同时宣告缓期2年执行。

• 死缓制度的执行：

① 没有再故意犯罪，2年期满后减为无期徒刑

② 有重大立功表现，2年期满后减为25年有期徒刑

③ 故意犯罪、情节恶劣的，报请最高院核准执行死刑

④ 故意犯罪未执行死刑的，执行期间重新计算。

(5) 死刑执行方法的限制：枪决或注射刑

3. 死缓限制减刑制度

➤《刑法修正案（八）》第4条规定：对被判处死刑缓期执行的累犯以及因故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力性犯罪被判处死刑缓期执行的犯罪分子，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定对其限制减刑。

➤2011年4月20日最高人民法院关于《刑法修正案（八）》时间效力问题的解释对死缓限制减刑问题的时间效力进行了规定：

“2011年4月30日以前犯罪，判处死刑缓期执行的，适用修正前刑法第五十条的规定。

被告人具有累犯情节，或者所犯之罪是故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力性犯罪，罪行极其严重，根据修正前刑法判处死刑缓期执行不能体现罪刑相适应原则，而根据修正后刑法判处死刑缓期执行同时决定限制减刑可以罚当其罪的，适用修正后刑法第五十条第二款的规定。”

➤最高人民法院于2011年4月25日公布了《关于死刑缓期执行限制减刑案件审理程序若干问题的规定》，该规定共计8个条文，体现出“撤销易追加难”的精神，其内容主要有如下几个方面：

1. 高级人民法院审理或者复核判处死缓并限制减刑的案件，认为原判对被告人判处死缓适当，但判决限制减刑不当的，应当改判，撤销限制减刑。反之，高级法院审理判处死缓没有限制减刑的上诉案件，认为应当限制减刑的，不得直接改判，也不得发回重新审判；确有必要限制减刑的，应当在第二审判决、裁定生效后，按照审判监督程序重新审判。而高级法院复核判处死缓没有限制减刑的案件，认为应当限制减刑的，不得以提高审级等方式对被告人限制减刑。

2. 高级法院审理判处死刑的第二审案件，对被告人改判死缓的，如果被告人符合刑法中限制减刑的规定，可以同时决定对其限制减刑。高级法院复核判处死刑后没有上诉、抗诉的案件，认为应当改判死缓并限制减刑的，可以提审或者发回重新审判。最高人民法院复核死刑案件，认为对被告人可以判处死缓并限制减刑的，应当裁定不予核准，并撤销原判，发回重新审判。

3. 被告人对第一审人民法院作出的限制减刑判决不服的，可以提出上诉。被告人的辩护人和近亲属，经被告人同意，也可以提出上诉。

★附加刑★

1. 罚金

人民法院判处犯罪分子向国家缴纳一定数额金钱的刑罚方法。

【区别】 罚款

罚款：行政处罚，行政机关对违法行为人处以金钱的处罚

罚金：刑事处罚，法院根据刑法规定对犯罪分子处以金钱的处罚

第十七章 刑罚裁量及制度

1. 累犯（必考）【案例】

(1) 概念：指受过一定的刑罚处罚，在刑罚执行完毕或者赦免以后，在一定的时间内又犯应当被判处一定刑罚之罪的犯罪分子。

(2) 分类

① 一般累犯：《刑法》第65条第1款 被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年内再犯应当被判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。

成立条件	具体内容
罪质条件	均为故意犯罪
刑度条件	均判有期徒刑以上刑罚
主体条件	均为年满18周岁的成年人
前提条件	后罪发生在前罪刑罚执行完毕或赦免以后
时间条件	5年之内

② 特殊累犯：

《刑法》第66条 危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪的犯罪分子，在刑罚执行完毕或者赦免以后，在任何时候再犯上述任一类罪的，都以累犯论处。（“太黑恐害国”）

★ 注意：特殊累犯不包括毒品犯罪，但是毒品犯罪是再犯从重处罚，效果上一致

(3) 刑事责任

应当从重处罚，不得缓刑和假释。

对于《刑修八》中关于累犯以及特殊累犯的规定的时间效力问题，司法解释有如下规定：

➤ 被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕或者赦免以后，在2011年4月30日以前再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是否构成累犯，适用修正前刑法第65条的规定；但是，前罪实施时不满18周岁的，是否构成累犯，适用修正后刑法第65条的规定。

➤ 曾犯危害国家安全犯罪，刑罚执行完毕或者赦免以后，在2011年4月30日以前再犯危害国家安全犯罪的，是否构成累犯，适用修正前刑法第66条的规定。

➤ 曾被判处有期徒刑以上刑罚，或者曾犯危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪，在2011年5月1日以后再犯罪的，是否构成累犯，适用修正后刑法第65条、第66条的规定。

2. 自首 ★★★（必考）

(1) 概念：指犯罪分子在犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的行为，或者被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的本人其他罪行的行为。

(2) 种类（必考分类）

① 一般自首：犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的行为

1. 自动投案

指犯罪尚未被发觉，或者虽被发觉但尚未被司法机关查获或被群众扭送，犯罪人主动将自己置于司法机关的合法控制下，接受司法机关的审查与裁判的行为。

➤ 司法解释关于几种特殊情况下“自动投案”的规定

2. 如实供述自己的罪行 ★★★

根据最高人民法院的前述解释, (1)“如实供述自己的罪行”,除供述自己的主要犯罪事实外,还应包括姓名、年龄、职业、住址、前科等情况。犯罪嫌疑人供述的身份等情况与真实情况虽有差别,但不影响定罪量刑的,应认定为如实供述自己的罪行,犯罪嫌疑人自动投案后隐瞒自己的真实身份等情况,影响对其定罪量刑的,不能认定为如实供述自己的罪行;(2)犯罪嫌疑人自动投案时虽然没有交代自己的主要犯罪事实,但在司法机关掌握其主要犯罪事实之前主动交代的,应认定为如实供述自己的罪行;(3)犯罪嫌疑人多次实施同种罪行的,应当综合考虑已交代的犯罪事实与未交代的犯罪事实的危害程度,决定是否认定为如实供述主要犯罪事实。虽然投案后没有交代全部犯罪事实,但如实交代的犯罪情节重于未交代的犯罪情节,或者如实交代的犯罪数额多于未交代的犯罪数额,一般应认定为如实供述自己的主要犯罪事实。无法区分已交代的与未交代的犯罪情节的严重程度,或者已交代的犯罪数额与未交代的犯罪数额相当,一般不认定为如实供述自己的主要犯罪事实;(4)犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的,只对如实供述部分犯罪的行为,认定为自首;(5)共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人,除如实供述自己的罪行,还应当供述所知的同案犯,主犯则应当供述所知其他同案犯的共同犯罪事实,才能认定为自首;(6)犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的,不能认定为自首,但在一审判决前又能如实供述的,应当认定为自首。

核心：只要不是被**强制要求交代**的（如拘传），**如实交代主要犯罪事实**基本都可以被认定为自首。

② **特殊自首：**被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人的其他罪行的行为

核心：交代**主要罪行**

1. 适用对象的特殊性

自首的主体是已经被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯等

2. 适用条件的特殊性

如实供述司法机关还未掌握的本人的其他罪行

★ **注意：**对向犯只能是自首不是立功

(3) 单位自首

单位集体决定或者单位负责人投案的，认定为单位自首。除了单位自首之外，如果其他人并不是自动投案但是如实交代罪行的，也认定为自首。

(4) 自首的刑事责任

1. 对自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚

2. 犯罪较轻的，可以免除处罚

3. 坦白（【区】自首）

被动归案+主动交代

4. 立功

指犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件的情况。

5. 数罪并罚（必考）

(1) 概念（背）

指刑罚规定的一人犯有数罪而由审判机关依照刑法规定的原则和方法合并处罚的制度。

(2) 我国数罪并罚的原则

以限制加重原则为基础，兼采其他原则的合理因素

① 吸收原则：死刑、无期徒刑吸收其他主刑

② 限制加重原则：数罪均有有期徒刑、拘役或管制

在总和刑期以下，个刑最高刑期以上酌情选择刑期

★ 注意：异种自由刑中有管制（“小强”）的，管制需并科

③ 并科原则：异种附加刑并科；同种附加刑限制加重或吸收

(3) 适用数罪并罚的三种情形

① 判决宣告以前一人犯数罪的合并处罚规则：

数罪不同种类，同种数罪不并罚

② 刑罚执行期间发现漏罪的合并处罚规则：

同种、不同种数罪均可，应“先并后减”

③ 刑罚执行期间又犯新罪的合并处罚规则：

同种、不同类数罪均可，应“先减后并”

6. 缓刑的法律后果

刑罚没有执行完毕就不存在累犯的适用问题

7. 假释

(1) 本质：监外执行（属于执行）

(2) 假释具有限制性（81条第2款）（必考）：不是累犯和严重的暴力犯罪（故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力性犯罪并被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑）

8. 减刑的对象

只适用于被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑（无“死刑”）的犯罪分子。

缓刑也可以减刑。

客观归属判断

主观归属判断

客观归责判断（期待可能性、当罚性、..）